

บทที่ 6

บทสรุปและเสนอแนะ



จากการศึกษาเรื่องการใช้อนุญาบาลอิสลามในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล
สรุปได้ว่า ประเทศที่มีมุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อย ได้เห็นถึงความสำคัญของอนุญาบาลอิสลามในฐานะ
ที่เป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ในเรื่องครอบครัวและมรดกของมุสลิม จึงได้ยอมรับให้นำเอาอนุญาบาล
อิสลามมาบังคับใช้ในชุมชนมุสลิม โดยเฉพาะบริเวณที่มุสลิมอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและมีประวัติดำเนินการ
เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยเหตุผลหลายประการด้วยกัน แต่ประการที่สำคัญที่สุดก็คือ รัฐมุ่งที่จะ
เสริมสร้างสังคมชาวไทยมุสลิมให้ดำเนินไปโดยปกติสุขในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจ
และเพื่อเป็นหลักประกันเสรีภาพในการนับถือศาสนาและแสดงให้เห็นว่ารัฐได้ให้ความสำคัญแก่ศาสนา
อิสลาม โดยส่งเสริมให้ประเพณีปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม โดยปราศจากการตั้งข้อรังเกียจ
จากทางรัฐบาลอันจะนำไปสู่ความแตกแยกในความรู้สึก ร่วมกันในการเป็นคนไทย ซึ่งจะช่วยให้
ประเทศขาดความเป็นเอกภาพ ความเป็นเอกภาพของประเทศชาตินั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อความ
สงบสุขและการพัฒนาประเทศให้ก้าวรุดหน้าต่อไป

จากอดีตในยุคล่าอาณานิคม นับว่าเป็นยุคที่กฎหมายอิสลามได้รับผลกระทบจากลัทธิ
ล่าอาณานิคมเป็นอย่างมาก แต่ในที่สุดด้วยความยินยอมอันเต็มตัวของมุสลิมก็สามารถนำกฎหมาย
อิสลามมาใช้กระแสแนวความคิด ประชัญญาของชาตินิยมตะวันตกมาได้ตราเป็นกฎหมายนี้ แต่ผลที่เกิด
จากประชัญญาของชาตินิยมตะวันตกนั้นก็คือ การประมวลกฎหมายอิสลามขึ้นมาเพื่อง่ายต่อการใช้หรือ
อ้างอิง แม้ว่าการประมวลกฎหมายในยุคนั้นจะเป็นเพียงการรวบรวมเอาคำอธิบายกฎหมาย
อิสลามของผู้รอบรู้ในยุคนั้นมารวบรวมเอาไว้ด้วยกันเท่านั้นก็ตาม แต่ประมวลกฎหมายอิสลาม
เหล่านั้นก็ได้กลายมาเป็นรากฐานในการใช้อนุญาบาลอิสลามในยุคปัจจุบัน เช่นในประเทศฟิลิปปินส์
ศรีลังกา สิงคโปร์หรือแม้แต่ในประเทศไทยก็จำเป็นต้องร่างหลักคำแปลกฎหมายอิสลามขึ้น เพื่อเป็น
คู่มือของตะดีะยุติธรรม เพื่อจะได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามได้เหมือนกัน

เมื่อสิ้นสุดยุคล่าอาณานิคม แต่บทบาทของกฎหมายอิสลามก็ไม่ได้สิ้นสุดลงไปตามลัทธิล่าอาณานิคม ประเทศต่าง ๆ ที่หลุดพ้นจากลัทธิล่าอาณานิคมต่างก็เร่งรีบจะสร้างความเป็นเอกภาพขึ้นในประเทศ เพื่อจะได้พัฒนาประเทศชาติของตนและรัฐบาลก็ได้เล็งเห็นถึงบทบาทของกฎหมายอิสลามในอันที่จะสร้างความสามัคคีกันภายในชาติ จึงให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอิสลามให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของมุสลิมที่จะดำเนินไปภายใต้หลักการคำสอนอิสลาม โดยการตราเป็นรูปพระราชบัญญัติหรือประมวลกฎหมายจากระบบการใช้กฎหมายอิสลามที่มีลักษณะเป็นพระราชบัญญัติ หรือประมวลกฎหมายนั้นได้กำหนดโครงสร้างการใช้กฎหมายอิสลามขึ้น เพื่อให้เกิดความแน่นอนในการบังคับใช้ เพราะการใช้กฎหมายอิสลามนั้นเป็นกฎหมายพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เอาไว้ เช่นขอบเขตการใช้กฎหมายอิสลาม วิธีพิจารณาคดีตามกฎหมายอิสลาม ตลอดจนองค์กรในการบริหารกฎหมายอิสลาม

สำหรับประเทศไทย แม้จะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูลพ.ศ. 2489 ก็ตาม ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวยังขาดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นโครงสร้างสำหรับการใช้กฎหมายอิสลาม เพียงแต่กำหนดให้ศาลชั้นต้นโดยคณะตุลาการเป็นผู้นิยามข้อขัดแย้งของกฎหมายอิสลาม ไม่ได้กำหนดขอบเขตการใช้กฎหมายอิสลามและวิธีพิจารณาคดีตามกฎหมายอิสลามเอาไว้เป็นการเฉพาะ ตลอดจนสถาบันทางศาสนาอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารกฎหมายอิสลามเหมือนกับประเทศฟิลิปปินส์ จึงก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ การใช้กฎหมายอิสลามจึงไม่อาจจะสนองตอบนโยบายของรัฐในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือบางทีอาจพูดได้ว่าส่วนทางก้นนโยบายของรัฐผู้ทำวิทยานิพนธ์เห็นว่าปัญหาที่เกิดจากการใช้กฎหมายอิสลามนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงสร้างของการใช้กฎหมายอิสลามยังไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐดังกล่าว ผู้ทำวิทยานิพนธ์จึงขอเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลามเพื่อเป็นแนวทางกว้าง ๆ ในเรื่องดังต่อไปนี้คือ

1. ขอบเขตการใช้กฎหมายอิสลาม เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามฯ ไม่ได้กำหนดเขตอำนาจศาลสำหรับพิจารณาคดีตามกฎหมายอิสลามเอาไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องถือตามเขตอำนาจศาลของศาลชั้นต้น ซึ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตามบทบัญญัติของมาตราดังกล่าวได้กำหนดเขตอำนาจศาล

ไว้ว่า ถ้าเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินเหล่านั้น ให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์สินเหล่านั้นตั้งอยู่ในเขตศาล และถ้าเป็นคำฟ้องอื่น ๆ นอกจากนั้นให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล ซึ่งมิมีปัญหาในทางปฏิบัติว่าจะนำมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ในกรณีมาตรา 3 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามเพียงใด เพราะเรื่องนี้ยังถกเถียงกันในหมู่นักกฎหมาย ศาลฎีกาเองก็เคยตีความว่าคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดก ถ้าทรัพย์สินตั้งอยู่นอกเขต 4 จังหวัดภาคใต้ ก็ไม่ทำให้ศาลในท้องที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่มีอำนาจนำกฎหมายมาใช้ (ฎ. 1286/2481) แต่ถ้าเป็นคำชี้ขาดคดีมรดกที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ใน 4 จังหวัดภาคใต้ แม้อิสลามคำตัดสินที่เป็นโจทก์ และจำเลยจะมีภูมิลำเนาในจังหวัดอื่น แต่โดยผลของมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ทำให้ต้องนำคดีไปฟ้องยังศาลใน 4 จังหวัดภาคใต้ ศาลนั้นก็ยังมีอำนาจนำกฎหมายอิสลามมาบังคับใช้ได้

ส่วนในคดีที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น ค้ำขอในคดีไม่มีข้อพิพาทหรือการฟ้องหย่า ซึ่งถือเอาภูมิลำเนาจำเลยเป็นหลัก การนำเอามาตรา 4 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาผูกกับมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลาม ทำให้โจทก์ต้องฟ้องจำเลย ณ ศาลในท้องที่ที่จำเลยมีภูมิลำเนา เป็นเหตุให้จำเลยหลบเลี่ยงได้ด้วยการภูมิลำเนาออกนอก 4 จังหวัดภาคใต้ เช่น ย้ายจากจังหวัดสตูลไปอยู่เชียงใหม่ หรือแม้แต่ไกลเคียงกัน เช่น จากจังหวัดปัตตานีไปยังจังหวัดสงขลา (พรมแดนติดกัน) ก็จะทำให้จำเลยหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในกรณีที่ดินเห็นว่าเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ซึ่งไม่น่าจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้น

เนื่องจากปัญหาดังกล่าวมาแล้ว จึงควรจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขขอบเขตการใช้กฎหมายอิสลาม โดยกำหนดให้ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ได้หลักกฎหมายอิสลามในเขต 4 จังหวัดภาคใต้ ต้องบังคับตามกฎหมายอิสลาม เพราะแสดงให้เห็นแต่แรกว่า คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายอิสลามจึงต้องมาทำการสมัครภายใต้หลักกฎหมายอิสลามในเขต 4 จังหวัดภาคใต้ ฉะนั้น ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากการสมัครจึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายอิสลามและศาลใน 4 จังหวัดภาคใต้มีอำนาจที่จะพิจารณาคดีเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกของผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ได้หลักกฎหมายอิสลามในเขต 4 จังหวัดภาคใต้โดยไม่คำนึงถึงมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาการย้ายภูมิลำเนาเพื่อหลีกเลี่ยงผลการบังคับของกฎหมายอิสลามได้ เพราะแม้ว่าจำเลยจะย้ายภูมิลำเนาออกไปนอกเขต 4 จังหวัดภาคใต้ คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถจะฟ้องคดีในศาล 4 จังหวัดได้ การที่ปล่อยให้มีการย้ายภูมิลำเนาเพื่อหลีกเลี่ยงผลบังคับของกฎหมายอิสลาม อาจก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมด้วยกัน เพราะไม่มีหลักประกันของผลบังคับของกฎหมาย

อิสลาม และอาจก่อให้เกิดความแตกแยกในชุมชนมุสลิม ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ

2. ควรจะมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณาใช้กฎหมายอิสลามเองได้ แต่การแก้ไขกฎหมายในเรื่องดังกล่าวนี้จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงโครงสร้างการใช้กฎหมายอิสลามด้วย เนื่องจากแม้ว่ารัฐจะแก้ไขกฎหมายโดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณาใช้กฎหมายอิสลามได้เลยก็อาจเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจจะทราบรายละเอียดของกฎหมายอิสลามได้ และไม่ทราบว่าผู้ที่มายื่นคำขอต่อทางการนั้นเป็นผู้มีสิทธิอันเกิดจากสถานทางครอบครัวตามกฎหมายอิสลามหรือไม่

ดังนั้น จึงควรจะต้องตั้งสถาบันทางศาสนาอิสลามขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่พิจารณาจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอันเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกของมุสลิม โดยแยกพิจารณาดังนี้

(1) การจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า โดยปกติแล้วการสมรส การหย่าของมุสลิมจะอยู่ในหน้าที่ของโต๊ะอิหม่ามประจำแต่ละมัสยิด เมื่อทำพิธีสมรสแล้วโต๊ะอิหม่ามจะต้องทำทะเบียนการสมรสและออกใบสำคัญการสมรส (ใบสำคัญนิกะห) แก่คู่สมรสเพื่อเป็นหลักฐานแสดงตัว ดังนั้น ในการแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้ก็โดยการยอมรับการจดทะเบียนสมรสที่กระทำโดยโต๊ะอิหม่ามภายใต้การควบคุมดูแลของทางการ กล่าวคือ เมื่อโต๊ะอิหม่ามพิจารณาเห็นว่าการสมรสนั้นเป็นไปตามกฎหมายอิสลามแล้ว ก็ทำการจดทะเบียนสมรส แล้วส่งใบสำคัญการสมรสนั้นให้นายทะเบียน (นายอำเภอหรือปลัดอำเภอ) ลงนาม แล้วมอบใบสำคัญการสมรสให้แก่คู่สมรส พร้อมทั้งเก็บสำเนาใบสำคัญการสมรสไว้ที่สำนักงานทะเบียนอำเภอและที่มัสยิด ส่วนในกรณีการสมรสครั้งต่อมาของชายในขณะที่ภรรยาอยู่ก่อนแล้ว จะต้องได้รับการยินยอมเป็นหนังสือจากภรรยา และในกรณีการหย่า (ตอละ) จะกระทำได้โดยการจดทะเบียนเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นควรจะต้องกำหนดให้โต๊ะอิหม่ามมีอำนาจที่จะทำการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าการสมรส การหย่านั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายอิสลาม และถือว่าโต๊ะอิหม่ามเป็นเจ้าพนักงานตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งอาจจะต้องบังคับตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดต่อเจ้าพนักงาน และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และได้รับคำตอบจากทางราชการ

หนังสือสำคัญที่ออกโดยนายทะเบียนถือว่าเป็นเอกสารมหาชน และเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นเพื่อแสดงว่าการสมัคร การหย่าได้กระทำโดยถูกต้อง และถือว่าการจดทะเบียนสมัครทะเบียนหย่าไม่มีผลถึงความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ของการสมัครหรือการหย่าแต่ประการใด คำพิพากษาของศาลเท่านั้นที่จะแสดงว่าการสมัครใดเป็นโมฆะ

สำหรับคู่กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติหน้าที่ของโต๊ะอิหม่ามก็อาจจะนำเป็นคดีฟ้องร้องต่อศาล เพื่อให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดได้ เมื่อศาลชี้ขาดอย่างไร เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ต้องปฏิบัติตามคำชี้ขาดนั้น

ผลจากการจดทะเบียนนั้นจะทำให้มุสลิมนำไปสู่การสมัคร การหย่าไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับรองสิทธิอันเกิดจากสถานะทางครอบครัวได้โดยไม่ต้องฟ้องร้องต่อศาลก่อน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็สามารถพิจารณาใช้กฎหมายอิสลามได้เลย ส่วนจะมีผู้ใดโต้แย้งอย่างไรรั้น เป็นเรื่องของคู่กรณีที่จะฟ้องร้องกันเอง เพื่อให้ศาลชี้ขาด

(2) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องครอบครัวและมรดกของมุสลิม การใช้กฎหมายอิสลามมีความจำเป็นที่จะให้มีคนกลางเพื่อทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยปรองดองข้อพิพาทของมุสลิม เพราะการไกล่เกลี่ยปรองดองเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับการแก้ไขข้อขัดแย้งในสังคมมุสลิม โดยการกำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งอยู่ในคณะกรรมการมัสยิดและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในกฎหมายอิสลามโดยความเห็นชอบของทางราชการ ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยปรองดองข้อพิพาทในเรื่องที่เกี่ยวข้องครอบครัวและมรดกมุสลิม ผลของการปรองดองสามารถที่จะนำไปยืนยันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามได้ เช่นการปรองดองในเรื่องการแบ่งส่วนมรดก ถ้าผลของการปรองดองเป็นอย่างไร เจ้าหน้าที่งานที่ดินก็ต้องดำเนินการแบ่งมรดกไปตามส่วนที่คณะกรรมการได้ปรองดอง แต่ถ้าคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการปรองดองหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถจะนำข้อพิพาทนั้นไปฟ้องร้องยังศาลได้

3. การอุทธรณ์ฎีกาสำหรับคดีแพ่งอิสลาม เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามมาตรา 4 วรรค 3 บัญญัติว่า คำวินิจฉัยชี้ขาดของโต๊ะยุติธรรมให้เป็นอันเด็ดขาด ทำให้ผู้ทบทวนฎีกาคำวินิจฉัยชี้ขาดของโต๊ะยุติธรรมไม่ได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่ความ จึงควรจะได้มีการแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้ให้คู่ความอุทธรณ์ฎีกาคำวินิจฉัยของโต๊ะ

ยุติธรรมได้ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์คณะหนึ่งในศาลอุทธรณ์ คณะกรรมการนี้ประกอบด้วยผู้รอบรู้คดีมีวิริยอุตสาหะ ขำดีและเชี่ยวชาญกฎหมายอิสลาม ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในภาษาอาหรับไม่เกิน 3 คน โดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือสำนักงานกฤษฎีกา-ราชมนตรีเป็นผู้เสนอรายชื่อทำหน้าที่พิจารณาคดีอุทธรณ์ร่วมกับผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือว่าถึงที่สุด

นอกจากนี้ก็ควรกำหนดวิธีพิจารณาคดีสำหรับคณะกรรมการอุทธรณ์ขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อจะทำให้การพิจารณาคดีของคณะกรรมการอุทธรณ์เป็นไปโดยรวดเร็วและยุติธรรม สำหรับคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการอุทธรณ์ก็สามารถถือเป็นบรรทัดฐานในคดีต่อ ๆ มา ซึ่งเป็นการสร้างหลักกฎหมายอิสลามขึ้นมา และจะเป็นการพัฒนากระบวนการกฎหมายอิสลามให้มั่นคงต่อไป

4. คุณสมบัติการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะตุ้ะยุติธรรม บทบาทของคณะตุ้ะยุติธรรมในฐานะที่เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามนั้นนับว่ามีความสำคัญต่อการใช้กฎหมายอิสลามเป็นอย่างยิ่ง เพราะการใช้กฎหมายอิสลามจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ การคัดเลือก และการแต่งตั้งคณะตุ้ะยุติธรรมว่ามีความเหมาะสมเพียงไร จากการศึกษารายงานเรื่องนี้พบว่า บทบัญญัติของกฎหมายอิสลามในเรื่องดังกล่าวยังไม่มีความเหมาะสม สุ่มควรจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยแยกพิจารณาได้ดังนี้

(1) คุณสมบัติของคณะตุ้ะยุติธรรม ตามบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดคุณสมบัติของคณะตุ้ะยุติธรรมเอาไว้ว่าจะต้องมีภูมิลำเนาในศาสนาอิสลามพอที่จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก และมีความรู้ภาษาไทยเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา

การกำหนดคุณสมบัติของคณะตุ้ะยุติธรรมไว้เพียงเท่านี้จึงนับว่าไม่เป็นการเหมาะสมกับฐานะและบทบาทของคณะตุ้ะยุติธรรม จึงควรจะได้มีการปรับปรุงคุณสมบัติของคณะตุ้ะยุติธรรมใหม่เนื่องจากการกำหนดคุณสมบัติเพียงแต่มีความรู้ทางศาสนาอิสลามพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามได้ เป็นการยากแก่การตรวจสอบว่ามีความรู้ในกฎหมายอิสลามมากน้อยเพียงไร ประกอบกับกฎหมายอิสลามมีความยุ่งยากซับซ้อน ผู้ที่จะวินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลามได้จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในกฎหมายอิสลามเป็นอย่างดี ดังนั้น จึงควรจะได้กำหนดให้ผู้ที่จะสมัครคัดเลือกเป็นคณะตุ้ะยุติธรรมจะต้องมีคุณสมบัติเป็นชาวมุสลิมจบปริญญาตรีทางกฎหมายอิสลาม ส่วนผู้ที่ไม่จบปริญญาตรีกฎหมาย

อิสลามจะต้องมีคุณวุฒิผ่านการอบรมหรือผ่านการสอบความรู้ทางกฎหมายอิสลามจากสถาบันทาง
ศาสนาอิสลาม เป็นต้นว่า สำนักจุฬาราชมนตรีหรือกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย-
ภายใต้การดูแลของทางราชการ¹

¹โดยที่รัฐเห็นว่าหลักเกณฑ์และ วิธีการบรรจุและแต่งตั้งตะโตะ
ยุติธรรมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521 ยังไม่เหมาะสม สืบควรกำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการดังกล่าวเสียใหม่ โดยให้ผู้สมัครเป็นตะโตะยุติธรรมได้รับการอบรมและทดสอบภูมิรู้
ในหลักกฎหมายอิสลามและความรู้ในหน้าที่และจริยธรรมของตุลาการจากคณะกรรมการอบรม
ซึ่งได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521 โดยกำหนดให้

"ข้อ 1 เมื่อจะต้องมีการบรรจุและแต่งตั้งตะโตะยุติธรรม ให้อธิบดีผู้พิพากษาภาค
ประกาศรับสมัครอิสลามคำลั่น ซึ่งมีความสัมพันธ์ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521 เพื่อดำเนินการอบรม ทดสอบ คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งเป็น
ตะโตะยุติธรรม

ข้อ 2 เมื่อพ้นกำหนดเวลารับสมัครแล้ว ให้อธิบดีผู้พิพากษาภาคจัดให้ผู้สมัครได้รับการ
อบรมในหลักกฎหมายอิสลาม หน้าที่และจริยธรรมของตุลาการ จากคณะกรรมการอบรมซึ่ง กระทรวง
ยุติธรรมแต่งตั้ง

หลังการอบรม ให้คณะกรรมการอบรมทำการทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมว่า
มีภูมิรู้ในหลักกฎหมายอิสลามพอที่จะ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลาม เกี่ยวกับครอบครัวและ
มรดก และมีความรู้ในหน้าที่และจริยธรรมของตุลาการสมควรจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งตะโตะยุติธรรมได้ แล้วเสนอรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบดังกล่าวไปยัง
อธิบดีผู้พิพากษาภาค

ให้อธิบดีผู้พิพากษาภาคปรึกษากับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
แล้ว เสนอชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาภาคเห็น
สมควรจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตะโตะยุติธรรมไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำหรับความรู้ภาษาไทยก็มีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตะโตะยุติธรรมไม่น้อยไปกว่าความรู้ทางศาสนาอิสลาม เพราะตะโตะยุติธรรมจะต้องร่วมศึกษาอัลกุฎหมายอิสลามกับผู้พิพากษา รับฟังพยานในการพิจารณา และนอกจากนั้นจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในเรื่องกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนระเบียบปฏิบัติของทางราชการอื่น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณาคดี จึงควรที่จะกำหนดให้ผู้ที่จะสมัครคัดเลือกเป็นตะโตะยุติธรรมจะต้องมีความรู้ภาษาไทยไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรืออย่างน้อยก็ผ่านการอบรมหรือสอบผ่านความรู้ภาษาไทยที่ทางราชการจัดขึ้นโดยเฉพาะ

(2) การคัดเลือกและแต่งตั้งตะโตะยุติธรรม เนื่องจากบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งตะโตะยุติธรรมในปัจจุบันยังไม่มีที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ตะโตะยุติธรรม ซึ่งจะเป็นผลเสียหายต่อระบบการบริหารกฎหมายอิสลาม และเสียหายต่อชุมชนมุสลิมได้ จึงควรที่จะแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยกำหนดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติดังที่ได้กล่าวมาแล้วตามข้อ (1) จึงให้ตะโตะอิหม่ามเป็นผู้คัดเลือกบุคคลดังกล่าวแล้ว เสนอให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งต่อไป

5. ควรบรรจุหลักกฎหมายอิสลามไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามฯ ลักษณะการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยนั้นแตกต่างจากของประเทศฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ คือในประเทศดังกล่าวได้กำหนดรายละเอียดเนื้อหาของกฎหมายอิสลามที่จะนำมาปรับใช้กับคดีเอาไว้ในกฎหมายว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลาม แต่ในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามฯ นั้น กำหนดเพียงให้เอากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้แทนบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดกเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเนื้อหาของกฎหมายอิสลามที่จะนำมาบังคับใช้แทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้บรรจุไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงต้องยึดถือตามคำแปลหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกโดยตะโตะยุติธรรมได้ให้คำรับรองหลักกฎหมายอิสลามดังกล่าวว่า จะใช้คำแปลหลักกฎหมายอิสลามนั้นเป็นหลักวินิจฉัยข้อพิพาทในคดีอันเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก จะไม่นำคำพิพากษาอื่นใดมาใช้บังคับแก้คดีดังกล่าว

ข้อ 3 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นสมควรให้ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบตามข้อ 2 ผู้ใดเป็นตะโตะยุติธรรม ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอ ก.ต. เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงดำเนินการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งต่อไป"

จะเห็นว่าคำแปลหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกนั้น ไม่ได้มีฐานะเป็นกฎหมายอย่างกฎหมายแพ่ง เป็นแต่เพียงหนังสือคู่มือของตะโต๊ะยุติธรรมเท่านั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนมุสลิมทั่ว ๆ ไป จึงไม่อาจหยิบยกข้อกฎหมายตามหลักกฎหมายอิสลามดังกล่าวมาอ้างอิงหรือยืนยันสิทธิได้ สิ่งควรที่จะนำเอาหลักกฎหมายอิสลามที่แปลจากต้นฉบับเดิม ซึ่งเป็นภาษาอาหรับมาประมวลและมาบรรจุไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามฯ ซึ่งจะเป็นผลทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนมุสลิมทั่ว ๆ ไปสามารถที่จะอ้างหลักกฎหมายดังกล่าวได้ เหมือนกับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดก โดยจะเป็นการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับการใช้กฎหมายอิสลามนอกศาลอีกทางหนึ่งด้วย

ท้ายที่สุดนี้ ผู้ทำวิทยานิพนธ์ขอเสนอรูปแบบในการแก้ไขปัญหาการใช้กฎหมายอิสลามทั้งหมดดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยการรวบรวมเป็นบทบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล ซึ่งจะเป็นการง่ายที่จะนำมาใช้และป้องกันการนำเอากฎหมายอิสลามมาใช้อย่างผิด ๆ จะทำให้การใช้กฎหมายอิสลามบรรลุเป้าหมายลุ่มกับเจตนารมณ์ของรัฐที่มุ่งจะเสริมสร้างชาวไทยมุสลิมให้ดำเนินไปโดยปกติสุขในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติศาสนกิจ และเพื่อเป็นหลักประกันเสรีภาพในการนับถือศาสนา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด

